

KOMMENTAR TIL ARTIKEL 15 OM BESKATNING AF INDKOMST FRA ANSÆTTELSESFORHOLD¹

Stk. 1

1. Stk. 1 fastsætter hovedreglen med hensyn til beskatning af indkomst fra ansættelsesforhold (undtagen pensioner), nemlig, at sådan indkomst kan beskattes i den stat, hvori det med ansættelsen forbundne arbejde faktisk er udført. Spørgsmålet om, hvorvidt tjenesteydelser udføres i et ansættelsesforhold, giver undertiden anledning til vanskeligheder, der diskuteres nedenfor under pkt. 8.1 ff. Arbejde i et ansættelsesforhold anses for at være udført på det sted, hvor den ansatte fysisk er til stede på det tidspunkt, hvor det arbejde, for hvilket arbejdsvederlaget betales, udføres. Det er en følge heraf, at en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, og som erhverver vederlag fra ansættelsesforhold fra kilder i den anden stat, ikke kan beskattes i denne anden stat af sit vederlag, blot fordi resultaterne af dette arbejde udnyttes i denne anden stat.
2. Fra hovedreglen gøres kun undtagelse med hensyn til vederlag erhvervet af besætningsmedlemmer på skibe eller luftfartøjer i international trafik (art. 15, stk. 3), pensioner (art. 18) og med hensyn til vederlag og pensioner i forbindelse med offentligt hverv (art. 19). Vederlag uden for ansættelsesforhold til bestyrelsesmedlemmer i selskaber henhører under art. 16.
- 2.1 Medlemslandene har generelt forstået udtrykket "gage, løn og andet lignende vederlag" således, at det også omfatter personalegoder, der modtages i forbindelse med et ansættelsesforhold (f.eks. aktieoptioner, anvendelsen af en bolig eller en bil, syge- eller livsforsikringsdækning og betaling af medlemskab til foreninger).
- 2.2 Betingelsen i artiklen for, at kildestaten kan beskatte, er, at gage, løn og andet lignende vederlag hidrører fra arbejde udført i denne stat. Dette er tilfældet, uanset hvornår indkomsten betales til eller krediteres den ansatte, eller på anden måde endeligt erhverves af denne.
- 2.3 I nogle tilfælde er det vanskeligt at bestemme, hvilken del af gage, løn og andet lignende vederlag for personligt arbejde der kan henføres til arbejde udført i en bestemt stat. Pkt. 12.6-12.13 nedenfor beskæftiger sig med problemstillingen om tildeling af aktieoptioner til ansatte, som udfører arbejde i forskellige stater. En tilsvarende problemstilling kan opstå i forbindelse med udbetalinger efter ansættelsesforholdets ophør. Sådanne udbetalinger kan rejse spørgsmål i relation til overenskomsten i forskellige grænseoverskridende tilfælde, herunder i tilfælde, hvor sådanne betalinger er ydet til grænsegængere, til ansatte, som har arbejdet i flere forskellige lande i løbet af deres karriere, eller til ansatte, som er blevet sendt udenlands for at arbejde, og som er vendt tilbage, kort før ophøret af deres ansættelsesforhold. Uanset hvilken terminologi der anvendes til at beskrive disse betalinger, er det vigtigt at bestemme det faktiske vederlag for hver enkelt af sådanne betalinger på grundlag af de faktiske omstændigheder og forhold i hvert tilfælde for at kunne afgøre, om betalingen udgør "gage, løn og andet lignende vederlag", og

hvorvidt betalingen, eller en del heraf, kan anses for at være erhvervet ved udførelse af arbejde i en given stat. I de følgende punkter drøftes disse spørgsmål i relation til forskellige typer betalinger, der ofte finder sted i forbindelse med ophør af ansættelsesforhold.

- 2.4 Ethvert vederlag, som er udbetalt efter et ansættelsesforholdets ophør, men for arbejde udført før ansættelsesforholdets ophør (for eksempel gage eller bonus for den sidste arbejdsperiode eller kommission for salg udført i den periode), vil blive anset for at være erhvervet i den stat, hvori de relevante arbejdsaktiviteter har været udført.
- 2.5 En udbetaling for ikke-afholdte feriedage eller sygedage, som er optjent gennem det sidste arbejdsår, er den del af vederlaget for arbejdsperioden, der udløste retten til at modtage ferie- og sygedagpenge. En ansat kan også være berettiget til ved ansættelsesforholdets ophør at modtage betaling for ikke-afholdte feriedage og sygedage flere år bagud i tid. Medmindre de konkrete omstændigheder tilsiger noget andet, skal betalinger modtaget efter ansættelsesforholdets ophør som kompensation for ikke-afholdte feriedage og sygedage flere år bagud i tid anses som en ydelse, som den pågældende har været berettiget til som følge af de sidste 12 måneders beskæftigelse, fordelt forholdsmæssigt efter, hvor arbejdet har været udført i den pågældende periode. En situation, hvor en anden konklusion kunne være berettiget, vil være den, hvor det tydeligt af registreringer fremgår, at disse ferie- og sygedage relaterer sig til specifikke perioder af den forudgående beskæftigelse, og at betalingerne er vederlag netop for disse arbejdsperioder. Staterne skal dog tage hensyn til, at de ansatte allerede kan være blevet beskattet af disse ferie- og sygedage på tidspunktet for deres opståen. Antag for eksempel, at det følger af en stats nationale lovgivning, at feriedage og sygedage, som optjenes eller afholdes som følge af arbejde udført på den pågældende stats territorium, skal anses for at være skattepligtige i det skatteår, hvor det pågældende arbejde blev udført, og derfor er blevet beskattet i overensstemmelse hermed. I sådanne tilfælde skal den stat, hvor den tidligere ansatte var hjemmehørende på tidspunktet for denne efterfølgende udbetaling vedrørende ferie- og sygedage, indrømme lempelse for dobbeltbeskatning for denne skat, og alle de andre stater, hvori den tidligere ansatte har arbejdet gennem det sidste år af sin beskæftigelse, bør på tilsvarende måde tage hensyn til, at enhver betaling for forudgående års ikke-afholdte feriedage og sygedage, som allerede er blevet beskattet ud fra et periodiseringsprincip, ikke relaterer sig til arbejdsaktiviteter udført igennem det sidste år.
- 2.6 I nogle tilfælde er arbejdsgiveren forpligtet (af lovgivning eller af en kontrakt) til at opsiges den ansatte med et vist varsel. Såfremt den ansatte får besked på, at han ikke længere skal udføre sit arbejde, men blot får vederlaget for opsigelsesperioden udbetalt, er vederlaget tydeligvis blevet udbetalt i kraft af ansættelsesforholdet, og som følge deraf "hidrører"

¹ Før 2000 var overskriften til art. 15 "Personligt arbejde i tjenesteforhold" i modsætning til overskriften i art. 14 "Frit erhverv". Som følge af udeladelsen af sidstnævnte artikel blev overskriften til art. 15 ændret til at omfatte ansættelsesforhold, et udtryk, der mere almindeligt anvendes til at beskrive de aktiviteter, som artiklen finder anvendelse på (se nærmere om den historiske udvikling vedrørende art. 14 i bind II af den fulde udgave af OECD's modeloverenskomst). Det var ikke hensigten med denne ændring på nogen måde at ændre artiklens anvendelsesområde.

vederlaget derfra, jf. stk. 1. Vederlaget skal i sådanne tilfælde anses for at hidrøre fra den stat, hvor det er rimeligt at antage, at den ansatte ville have arbejdet i opsigelsesperioden. Vurderingen af, hvor det vil være rimeligt at antage, at den ansatte ville have arbejdet i opsigelsesperioden, må tage udgangspunkt i alle foreliggende omstændigheder. I de fleste tilfælde vil det være det sidste sted, hvor den ansatte har arbejdet igennem en længere periode forud for opsigelsen; det vil klart være urimeligt ved denne vurdering at tage hensyn til en mulig beskæftigelsesperiode i en stat, hvor den ansatte forventedes at have udført sit arbejde, men hvor han rent faktisk ikke har gjort det i en længere tidsperiode.

- 2.7 En anden situation er den, hvor arbejdsgiveren er forpligtet til at betale en fratrædelsesgodtgørelse som følge af et ansættelsesforholds ophør, hvad enten det beror på national lovgivning eller på en kontraktlig aftale. En sådan godtgørelse er ofte, omend ikke altid, beregnet på grundlag af den sidste del af ansættelsesperioden. Medmindre konkrete forhold indikerer noget andet, skal en sådan fratrædelsesgodtgørelse anses for at være omfattet af denne artikel for de sidste 12 måneders beskæftigelse, fordelt forholdsmæssigt mellem de stater, hvor arbejdet er blevet udført i den pågældende periode; vederlaget skal anses som vederlag for dette arbejdsforhold, jf. art. 15, stk. 1, sidste punktum.
- 2.8 Når en persons ansættelsesforhold ophører, kan den pågældende person have juridisk grundlag for at påberåbe sig, at det er sket i strid med kontraktforholdet, lovgivningen eller en kollektiv overenskomst; der kan herunder også være grundlag for at kræve erstatning, afhængigt af årsagerne til opsigelsen. Den pågældende kan modtage erstatning eller indgå forlig for brud på de relevante kontraktuelle eller juridiske forpligtelser. Den skattemæssige behandling af erstatningen vil afhænge af, hvad erstatningen skal dække. Ydes der for eksempel erstatning for en for kort opsigelsesperiode, eller fordi der ikke er betalt den fulde fratrædelsesgodtgørelse i henhold til loven eller kontrakten, skal erstatningen skattemæssigt behandles som det, den træder i stedet for. Pønalerstatning eller erstatning udbetalt for eksempel for diskrimination eller for at have skadet en persons omdømme, skal behandles anderledes; disse former for erstatning vil typisk falde ind under art. 21.
- 2.9 I henhold til bestemmelserne i en ansættelseskontrakt eller i et forlig indgået som følge af ansættelsesforholdets ophør kan en tidligere ansat modtage en godtgørelse for til gengæld ikke at udføre arbejde for en konkurrerende virksomhed eller sin tidligere arbejdsgiver. En sådan forpligtelse er stort set altid tidsbegrænset og ligeledes ofte geografisk afgrænset. Selv om en sådan betaling er direkte relateret til ansættelsesforholdet og derfor kan betegnes som "vederlag fra ansættelsesforhold", vil der som hovedregel ikke være tale om et vederlag, der er erhvervet som følge af aktiviteter udøvet før tidspunktet for ansættelsesforholdets ophør. Af samme årsag vil en sådan godtgørelse sædvanligvis blive beskattet i den stat, hvori modtageren er hjemmehørende på det tidspunkt, hvor godtgørelsen modtages. I de tilfælde, hvor en sådan godtgørelse udbetalt efter ansættelsesforholdets ophør reelt er en betaling for aktiviteter udført i løbet af ansættelsesforholdet (det kan for eksempel være tilfældet, hvis forpligtelsen til ikke at udføre konkurrerende arbejde kun har lille eller ingen værdi for den tidligere arbejdsgiver), skal godtgørelsen beskattes på samme måde som betalinger modtaget for arbejde udført i den sidste del af ansættelsesperioden. Det er ligeledes sådan i nogle stater, at en del af den ansattes månedlige

vederlag omfatter betaling for en forpligtelse til ikke at udføre arbejde for en konkurrerende virksomhed i en vis periode efter ansættelsesforholdets ophør, således at der ikke kommer til at foreligge noget særskilt vederlag for accepten af en sådan konkurrenceklausul ved ansættelsesforholdets ophør; i disse tilfælde er retningslinjerne i den første del af dette stykke ikke anvendelige, og i disse tilfælde skal derfor også den del af den løbende aflønning, der repræsenterer et vederlag for accepten af en konkurrenceklausul, beskattes på samme måde som resten af vederlaget.

- 2.10 Som det fremgår af pkt. 4-6 i kommentaren til art. 18, kan der finde flere forskellige former for betalinger sted i forbindelse med et ansættelsesforholds ophør, for så vidt angår den tidligere ansattes pensionsbidrag eller pensionsretigheder. I pkt. 6 i kommentaren hedder det, at: "Om en vis betaling skal anses som andet vederlag, der er lig en pension, eller som en endelig betaling for udført arbejde, der falder ind under art. 15, skal afgøres på grundlag af de faktiske forhold". Der nævnes det eksempel i punktet, at: "Tilbagebetaling af pensionsbidrag (f.eks. efter kortvarig ansættelse) er ikke omfattet af "andre lignende vederlag" under art. 18". I den udstrækning en sådan tilbagebetaling af pensionsbidrag som led i et ansættelsesforholds ophør vil være at betragte som yderligere vederlag for den tidligere ansættelse, vil den være dækket af art. 15 og skal som følge deraf anses for at være erhvervet i den stat, hvori arbejdet blev udført, da ansættelsesforholdet ophørte.
- 2.11 Visse udbetalinger kan, under hensyn til forskellige nærmere indgåede aftaler, ske efter ansættelsesforholdets ophør. Sådanne betalinger skal anses for at være omfattet af art. 15, og i den udstrækning disse betalinger relaterer sig til en specifik ansættelsesperiode i en given stat, skal de anses for at være vederlag for arbejdsaktiviteter udført i denne stat. Da mange stater ikke vil acceptere en udskydelse af skatten på arbejdsindkomst, selv ikke i tilfælde, hvor betalingen først finder sted efterfølgende, er det vigtigt, at stater, som beskatter sådanne vederlag modtaget efter ansættelsesforholdets ophør, også sikrer sig, at dobbeltbeskatning undgås.
- 2.12 Forskellige former for betaling ses modtaget efter ansættelsesforholdets ophør på grund af incitamentsaflønning i almindelighed og aktieoptioner i særdeleshed. Mens den skattemæssige behandling af sådanne betalinger vil afhænge af deres karakter, finder principperne anført nedenfor i pkt. 12-12.15, som specifikt vedrører aktieoptioner, også anvendelse i forbindelse med behandlingen af andre former for incitamentsaflønninger.
- 2.13 En ansat kan være berettiget til fortsat at være dækket af syge- eller livsforsikring i en vis periode efter ansættelsesforholdets ophør. Vedkommende kan også være berettiget til andre fordele, såsom at kunne benytte et jobsøgningsfirma. Medmindre de faktiske forhold tilsiger noget andet, skal sådanne fordele betragtes som værende vederlag, der er omfattet af denne artikel, og som hidrører fra den stat, hvor arbejdet blev udført, da ansættelsesforholdet ophørte (og da forpligtelsen til at betale for disse fordele derfor opstod).
- 2.14 En anden type betaling, som ses ydet i forbindelse med eller efter et ansættelsesforholds ophør, er en kompensation for fremtidigt tab af indkomst som følge af skade eller invaliditet forårsaget af forhold indtruffet under arbejdets udførelse. Den skattemæssige behandling af sådanne ydelser afhænger af den juridiske kontekst, som ligger til grund for dem. Er betalingen for eksempel sket som led i en social sikringsordning ("workers' compensation fund"), vil ydelsen eventuelt

skulle henføres til art. 18, 19 eller 21 (jf. pkt. 24 i kommentaren til art. 18). En betaling, der må betegnes som en pensionsbetaling, vil være omfattet af art. 18. En betaling, der sker, fordi den ansatte har juridisk grundlag for at kræve en erstatning som følge af arbejdsrelateret sygdom eller skader, vil sædvanligvis falde ind under art. 21. En betaling ydet af arbejdsgiveren i henhold til en ansættelseskontrakt, selv om sygdommen eller skaden ikke er arbejdsrelateret, eller selv om arbejdsgiveren ikke har skyld i sygdommen eller skaden, bør behandles på samme måde som en fratrædelsesgodtgørelse; medmindre de faktiske forhold tilsiger noget andet, bør en sådan ydelse anses for at være dækket af denne artikel for de sidste 12 måneders beskæftigelse, fordelt forholdsmæssigt under hensyntagen til, hvor arbejdet faktisk blev udført i den pågældende periode. En kortvarig invaliditetsydelse udbetalt som led i ansættelsesforholdet bør behandles på samme måde som betaling for sygedage under ansættelsesforholdet; en sådan betaling vil være omfattet af art. 15 (art. 17 for så vidt angår udøvende kunstnere og sportsudøvere), og den skal beskattes i den stat, hvor den ansatte i almindelighed var beskæftiget forud for sygdommen eller tilskadekomsten.

- 2.15 Efter ansættelsesforholdets ophør kan der ske det, at en sælger modtager en betaling for tab af fremtidig salgskommission. Den skattemæssige behandling af sådanne ydelser afhænger af den juridiske kontekst, som ligger til grund for dem. Afhængigt af omstændighederne vil betalingen kunne betragtes som et udskudt vederlag, som salgsmedarbejderen var berettiget til, baseret på tidligere salg, eller betalingen vil skulle foretages i henhold til en bestemmelse i ansættelseskontrakten, som sikrer sælgeren en kommission af ethvert fremtidigt salg til de kunder, som sælgeren har skaffet arbejdsgiveren; i begge tilfælde skal ydelserne behandles som vederlag for de arbejdsydelser, som gav ret til kommissionerne. En betaling, der skal kompensere for tab af den fremtidige kommission, som sælgeren formodentlig ville have opnået, hvis vedkommende fortsat havde arbejdet for den samme arbejdsgiver, kan også betragtes som en compensation for uretmæssig afskedigelse eller en form for fratrædelsesgodtgørelse; i de tilfælde, skal betalingen behandles som sådan.
- 2.16 Som en del af en overgangsordning, der fører til ophøret af et ansættelsesforhold, kan en ansat modtage fuld eller nedsat gage for en periode, hvor den pågældende ikke arbejder. Når lønnen udbetales af arbejdsgiveren i en periode, hvor den ansatte ikke er forpligtet til at arbejde, selv om ansættelsesforholdet ikke er afsluttet, hidrører gagen fortsat fra ansættelsesforholdet og udgør derfor vederlag, "der hidrører derfra", jf. stk. 1. Vederlaget bør i et sådant tilfælde anses for at være optjent i den stat, hvor det er rimeligt at antage, at den ansatte ville have arbejdet i denne periode, hvilket som oftest vil være den stat, hvori arbejdet blev udført indtil ophøret af arbejdet.

Stk. 2

3. Stk. 2 indeholder en generel undtagelse fra reglen i stk. 1. Denne undtagelse omfatter alle fysiske personer, der udfører tjenesteydelser i ansættelsesforhold (repræsentanter, bygningsarbejdere, ingeniører osv.) i den udstrækning, deres vederlag ikke falder ind under bestemmelserne i andre artikler, såsom de, der finder anvendelse på offentlige hverv eller på udøvende kunstnere og sportsudøvere.

4. De tre betingelser, der er foreskrevet i dette stykke, skal opfyldes, for at vederlaget kan være kvalificeret til fritagelse. Den første betingelse er, at fritagelsen er begrænset til 183-dagesperioden. Det er yderligere gjort til en betingelse, at denne periode ikke må overskrides "i nogen 12-månedersperiode, der begynder eller slutter i det pågældende skatteår". Dette står i modsætning til 1963-overenskomststudkastet og til 1977-modeloverenskomsten, som foreskrev, at 183-dagesperioden ikke måtte overskrides "i det pågældende skatteår", en formulering, der skabte vanskeligheder i tilfælde, hvor de kontraherende staters skatteår ikke faldt sammen, og som åbnede for muligheden for fordele i den forstand, at aktiviteterne undertiden blev tilrettelagt på en sådan måde, at eksempelvis arbejdere opholdt sig i den pågældende stat i de sidste 5½ måneder i et år og i de første 5½ måneder i det følgende år. Den nuværende affattelse af stk. 2, litra a), fjerner sådanne muligheder for skatteomgåelse. Artiklen skal forstås således, at alle perioder på 12 på hinanden følgende måneder skal tages i betragtning, selv perioder, der i et vist omfang overlapper hinanden. Hvis f.eks. en ansat er til stede i en stat i 150 dage mellem 1. april 01 og 31. marts 02, men er til stede dér i 210 dage mellem 1. august 01 og 31. juli 02, vil den ansatte have været til stede i en periode, der overstiger 183 dage i den anden ovenfor nævnte 12-månedersperiode, selv om den ansatte var til stede i under 183 dage i den førstnævnte periode og denne første periode delvis overlapper den anden periode.

- 4.1 Henvisningen til "det pågældende skatteår" skal fortolkes som en reference til skatteåret i den stat, hvori en hjemmehørende person i den anden stat har udført sit arbejde, og hvor de relevante arbejdsydelser er blevet udført. Antag for eksempel, at skatteåret i stat S går fra 1. januar til 31. december, og at en person, der er hjemmehørende i stat R, er til stede i stat S og udfører arbejdsydelser dér mellem 1. august 00 og 28. februar 01. Ved anvendelsen af stk. 2, litra a), skal enhver 12-månedersperiode, der begynder mellem 1. januar og 31. december 00, eller som slutter mellem 1. januar og 31. december 01, og i hvilken periode der er udført relevante arbejdsydelser, medregnes. Tag for eksempel 12-månedersperioden fra 1. august 00 til 31. juli 01, som begynder i skatteåret 00, og hvor en person var til stede i mere end 183 dage i stat S; her vil arbejdsydelserne udført i perioden 1. august til 31. december 00 blive medregnet; på tilsvarende måde er det sådan, at den 12-månedersperiode, der starter den 1. marts 00, og som slutter den 28. februar 01, og som ender i skatteåret 01, og hvor personen var til stede i stat S i mere end 183 dage, vil indbefatte arbejdsydelser udført i stat S i perioden 1. januar til 28. februar 01. Beskatningen af vederlaget for de relevante arbejdsydelser behøver ikke at finde sted i det pågældende skatteår; som det fremgår af pkt. 2.2 ovenfor og af pkt. 12.1 nedenfor, tillader artiklen staterne at beskatte vederlaget fra arbejde udført i den pågældende stat i et bestemt år, selv om vederlaget for disse arbejdsydelser er erhvervet, eller skatten pålignet, i et andet år.

5. Selv om medlemslandene har anvendt forskellige metoder ved beregningen af 183-dagesperioden, er der kun én måde, der er forenelig med ordlyden i dette stykke: metoden, der ser på "antallet af dage, hvor personen er fysisk til stede". Anvendelsen af denne metode er enkel og klar, idet den fysiske person enten er til stede i et land eller ikke er til stede. Tilstedeværelsen kan også relativt let dokumenteres af skattemynderen, når skattemyndighederne kræver bevis herfor. Ifølge denne metode skal følgende dage medtages ved bereg-

ningen: en del af en dag, ankomstdagen, afrejsedagen og alle andre dage, der tilbringes i den stat, hvor arbejdet udføres, såsom lørdage og søndage, nationale helligdage, ferier før, under og efter arbejdets udførelse, kortvarige afbrydelser af arbejdet (uddannelse, strejker, lockout, forsinkelser af leverancer), sygedage (medmindre de forhindrer personen i at forlade arbejdslandet, og han ellers ville være berettiget til fritagelse for beskæftning) og dødsfald eller sygdom i familien. Der skal imidlertid ved beregningen bortses fra dage, der tilbringes i arbejdsstaten i transit under en rejse mellem to steder uden for arbejdsstaten. Det følger af disse principper, at enhver hel dag, der tilbringes uden for arbejdsstaten, hvad enten der er tale om ferie, forretningsrejser eller andet, ikke skal tages i betragtning. En dag, i løbet af hvilken en del, uanset hvor kort, skatteyderen er til stede i en stat, tæller som en dag i denne stat i relation til beregningen af 183-dagesperioden.

5.1 Dage, på hvilke skatteyderen er hjemmehørende i kildestaten, skal imidlertid ikke tages i betragtning ved beregningen. Litra a) skal læses i sammenhæng med den første del af stk. 2, som henviser til "vederlag, som en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, erhverver fra ansættelsesforhold i den anden kontraherende stat", hvilket ikke finder anvendelse på en person, der er hjemmehørende, og arbejder, i den samme stat. Udtrykket "modtageren opholder sig i" i litra a), henviser til modtageren af vederlaget, og i en periode, hvor en person er hjemmehørende i kildestaten, kan denne ikke anses for at være modtageren af vederlag, der er erhvervet af en person hjemmehørende i en kontraherende stat med hensyn til et arbejde udført i den anden kontraherende stat. Følgende eksempler belyser dette:

- Eksempel 1: Fra januar 01 til december 01 bor X i, og er hjemmehørende i, stat S. Den 1. januar 02 bliver X ansat af en arbejdsgiver, der er hjemmehørende i stat R, og flytter til stat R, hvor han bliver hjemmehørende. Efterfølgende sendes X af sin arbejdsgiver til stat S fra den 15. til den 31. marts 02. I dette tilfælde er X til stede i stat S i 292 dage mellem 1. april 01 og 31. marts 02, men da han er hjemmehørende i stat S mellem 1. april 01 og 31. december 01, skal denne første periode ikke tages i betragtning ved beregningen af de perioder, der er omhandlet i litra a).
- Eksempel 2: Fra 15. til 31. oktober 01 er Y, der er hjemmehørende i stat R, til stede i stat S for at forberede en udvidelse i S af virksomheden ACO, der også er hjemmehørende i stat R. Den 1. maj 02 flytter Y til stat S, hvor hun bliver hjemmehørende og arbejder som direktør i et nyligt i stat S stiftet datterselskab af ACO. I dette tilfælde er Y til stede i stat S i 184 dage mellem 15. oktober 01 og 14. oktober 02, men da hun er hjemmehørende i stat S mellem 1. maj og 14. oktober 02, skal denne sidste periode ikke tages i betragtning ved beregningen af de perioder, der er omhandlet i litra a).

6. Den anden betingelse er, at arbejdsgiveren, der betaler vederlaget, ikke må være hjemmehørende i den stat, i hvilken arbejdet udføres. Nogle medlemslande er imidlertid af den opfattelse, at det er uhensigtsmæssigt at udstrække undtagelsen i stk. 2 til tilfælde, hvor arbejdsgiveren ikke er hjemmehørende i den stat, hvor den ansatte er hjemmehørende, da det i et sådant tilfælde kan være administrativt vanskeligt at fastsætte den ansattes indkomst og være vanskeligt at håndhæve en forpligtelse for arbejdsgiveren til at tilbageholde

skat. Kontraherende stater, der er af denne opfattelse, kan frit indsætte følgende alternative formulering i stk. 2, litra b):

b) vederlaget betales af eller for en arbejdsgiver, der er hjemmehørende i den førstnævnte stat, og".

6.1 Anvendelsen af den anden betingelse på skattemæssigt transparente interessentskaber skaber vanskeligheder, da sådanne interessentskaber ikke anses for en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat i henhold til art. 4 (jf. pkt. 8.8 i kommentaren til art. 4). Mens det er klart, at et sådant interessentskab kan betegnes som en "arbejdsgiver" (især i henhold til definitionen af dette udtryk i nogle landes lovgivning, f.eks. når en arbejdsgiver defineres som en person, der er indeholdelsespligtig), vil anvendelsen af betingelsen på interessentskabsniveau uden hensyn til interessenterens situation derfor gøre betingelsen helt meningsløs.

6.2 Meningen og hensigten med stk. 2, litra b) og c), er at undgå kildebeskatning i forbindelse med kortvarige ansættelsesforhold, i det omfang indkomsten fra ansættelsen ikke anses for en fradragsberettiget udgift i kildestaten, fordi arbejdsgiveren ikke er skattepligtig i denne stat, da arbejdsgiveren hverken er hjemmehørende eller har et fast driftssted i denne stat. Disse undtagelser kan også retfærdiggøres af det faktum, at det ville være forbundet med en meget betydelig administrativ belastning at kræve indeholdelse af kildeskat ved kortvarige ansættelsesforhold i de tilfælde, hvor arbejdsgiveren hverken er hjemmehørende i eller har et fast driftssted i denne stat. For at nå til en meningsfuld fortolkning af stk. 2, litra b), der er i overensstemmelse med bestemmelsens kontekst og formål, er det derfor vigtigt at være opmærksom på, at i forbindelse med skattemæssigt transparente enheder eller ordninger, f.eks. interessentskaber, anvendes dette litra på interessent- eller medlemsniveau. Begreberne "arbejdsgiver" og "hjemmehørende" i stk. 2, litra b), anvendes således på interessent- eller medlemsniveau frem for på den skattemæssigt transparente enhed eller ordning. Denne tilgang er i overensstemmelse med tilgangen ifølge art. 1, stk. 2, i henhold til hvilket en af andre overenskomstbestemmelser afledt fordel skal anvendes på indkomst, der beskattes på interessent- eller medlemsniveau, frem for på enheds- eller ordningsniveau, når enheden eller ordningen behandles som skattemæssigt transparent. Selv om denne fortolkning kan skabe vanskeligheder i tilfælde, hvor interessenterne eller medlemmerne er hjemmehørende i forskellige stater, kan sådanne vanskeligheder løses gennem den gensidige aftaleprocedure ved f.eks. at vælge den stat, i hvilken de deltagere eller medlemmer, der besidder størsteparten af andelen i enheden eller ordningen, er hjemmehørende.

7. Hvis arbejdsgiveren, jf. den tredje betingelse, har et fast driftssted i den stat, i hvilken arbejdet udføres, indrømmes fritagelsen, på betingelse af at vederlaget ikke udredes af dette faste driftssted. Udtrykket "udredes af" skal fortolkes i lyset af formålet med stk. 2, litra c), der er at sikre, at undtagelsen i stk. 2 ikke finder anvendelse på vederlag, der kan give anledning til et fradrag under hensyntagen til principperne i art. 7 og arten af vederlaget, ved beregningen af fortjenesten i et fast driftssted, der er beliggende i den stat, hvori arbejdet udføres.

7.1 Det faktum, at arbejdsgiveren rent faktisk har, eller ikke har, forlangt et fradrag for vederlaget ved beregningen af den fortjeneste, der kan henføres til det faste driftssted, er ikke nødvendigvis afgørende, da den korrekte test er, om noget fradrag, der ellers ville kunne indrømmes med hensyn til

- dette vederlag, skulle være taget i betragtning ved fastsættelsen af den fortjeneste, der kan henføres til det faste driftssted. Denne test vil f.eks. være opfyldt, selv om der rent faktisk ikke er fratrasket noget beløb som følge af, at det faste driftssted er fritaget for beskatning i kildestaten, eller fordi arbejdsgiveren simpelthen ikke ønsker at udnytte et fradrag, som han er berettiget til. Denne test vil også være opfyldt, når vederlaget ikke er fradragsberettiget som følge af dets karakter (f.eks. når staten er af den opfattelse, at udstedelse af aktier i forbindelse med en medarbejderaktieoption ikke kan fradrages), snarere end fordi det ikke skal henføres til det faste driftssted.
- 7.2 Med henblik på at fastsætte den fortjeneste, der kan henføres til et fast driftssted i henhold til art. 7, stk. 2, kan det vederlag, der betales til en ansat i et foretagende i en kontraherende stat for arbejde udført i den anden stat til fordel for foretagendets faste driftssted i denne anden stat, efter omstændighederne enten give anledning til et direkte fradrag eller et fradrag for et fiktivt beløb, f.eks. for tjenesteydelser leveret til det faste driftssted af en anden del af foretagendet. I det sidstnævnte tilfælde forholder det sig sådan, da det fiktive beløb er fastsat som følge af den fiktion om det separate og uafhængige foretagende, der anvendes i art. 7, stk. 2, og som alene er en mekanisme, der er fastsat i dette stykke med henblik på at fastsætte den fortjeneste, der kan henføres til et fast driftssted, påvirker denne fiktion ikke afgørelsen af, om vederlaget udredes af det faste driftssted.
8. Der er en direkte sammenhæng mellem de principper, der ligger bag undtagelsen i stk. 2, og art. 7. Art. 7 er baseret på det princip, at et foretagende i en kontraherende stat ikke skal undergives beskatning i den anden stat, medmindre dets erhvervsmæssige tilstedeværelse i denne anden stat har et omfang, der er tilstrækkeligt til at udgøre et fast driftssted. Undtagelsen i art. 15, stk. 2, udstrækker dette princip til beskatningen af de ansatte i et sådant foretagende, hvis disse ansattes aktivitet udøves i den anden stat i en relativt kort periode. Stk. 2, litra b) og c), gør det klart, at det ikke er hensigten, at undtagelsen skal gælde i tilfælde, hvor arbejdet udføres for et foretagende, hvis fortjeneste er undergivet beskatning i en stat, enten fordi det udføres af et foretagende, der er hjemmehørende i denne stat, eller fordi der i en stat er et fast driftssted, som arbejdet kan henføres til.
- 8.1 Det kan i visse tilfælde være vanskeligt at afgøre, om det arbejde, der udføres i en stat af en fysisk person, der er hjemmehørende i en anden stat, og som udføres for et foretagende, der er hjemmehørende i den første stat (eller som har et fast driftssted i denne stat), er arbejde i ansættelsesforhold, hvor art. 15 finder anvendelse, eller tjenesteydelser, der udføres af et separat foretagende, hvor art. 7 finder anvendelse, eller mere generelt, om undtagelsen finder anvendelse. Mens kommentaren tidligere behandlede tilfælde, hvor ordninger var struktureret med det hovedformål at opnå fordele af undtagelsen i art. 15, stk. 2, blev det erkendt, at lignende tilfælde kunne opstå i mange andre situationer, som ikke involverede skattemæssige transaktioner, og kommentaren blev ændret for at give en mere omfattende diskussion af disse spørgsmål.
- 8.2 I nogle stater vil der ikke i skattemæssig henseende blive sat spørgsmålstejn ved et formelt kontraktforhold, medmindre der foreligger tegn på manipulation. Disse stater er som følge af deres nationale lovgivning af den opfattelse, at arbejde i ansættelsesforhold kun udføres i tilfælde, hvor der er et formelt ansættelsesforhold.
- 8.3 Hvis stater, hvor dette er tilfældet, finder, at der er risiko for, at der indrømmes aftalefordele i henhold til undtagelsen i stk. 2 i situationer, der ikke var tilsigtede (f.eks. i tilfælde af "arbejdsudlejning"), kan de frit bilateralt aftale en bestemmelse, der kan affattes som følger: "Stk. 2 i denne artikel finder ikke anvendelse på vederlag, der erhverves af en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, for arbejde, der er udført i den anden kontraherende stat, og som betales af eller for en arbejdsgiver, som ikke er hjemmehørende i den anden stat, hvis:
- a) modtageren som led i arbejdet leverer tjenesteydelser til en anden person end arbejdsgiveren, og denne person, direkte eller indirekte, fører tilsyn med, leder eller kontrollerer den måde, hvorpå tjenesteydelserne udføres; og
 - b) tjenesteydelserne udgør en integreret del af den forretningsmæssige virksomhed, som udøves af denne person."
- 8.4 I mange stater er der imidlertid udviklet forskellige regler og kriterier i lovgivningen eller i retspraksis (f.eks. "substance over form"-regler) med det formål at sondre mellem tilfælde, hvor tjenesteydelser, der leveres af en fysisk person til et foretagende, skal anses for at være leveret i et ansættelsesforhold, og tilfælde, hvor sådanne tjenesteydelser skal anses for at være leveret i henhold til en kontrakt mellem to separate foretagender. Denne sondring er vigtig i forbindelse med anvendelsen af bestemmelserne i art. 15, især bestemmelserne i stk. 2, litra b) og c). Under hensyn til den begrænsning, der er beskrevet i pkt. 8.11 nedenfor – og medmindre andet bestemmes i en overenskomst – er det den nationale lovgivning i kildestaten, der er afgørende for, om tjenesteydelser, der er leveret af en fysisk person i denne stat, er udført i et ansættelsesforhold, og dette vil være afgørende for, hvorledes denne stat anvender overenskomsten.
- 8.5 I nogle tilfælde kan tjenesteydelser, der leveres af en fysisk person til et foretagende, anses for at være tjenesteydelser i et ansættelsesforhold i henhold til national lovgivning, selv om disse tjenesteydelser leveres i henhold til en formel kontrakt mellem på den ene side det foretagende, der har rekvireret tjenesteydelserne, og på den anden side enten den fysiske person selv eller et andet foretagende, som personen formelt er ansat i, eller med hvilket personen har indgået en anden formel kontrakt om tjenesteydelser.
- 8.6 I sådanne tilfælde kan der i den relevante nationale lovgivning ses bort fra den måde, hvorpå tjenesteydelserne er karakteriseret i de formelle kontrakter. Det kan i lovgivningen foretrækkes primært at fokusere på arten af de tjenesteydelser, der leveres af den fysiske person, og deres indpasning i den virksomhed, der udføres af det foretagende, der rekvirerer tjenesteydelserne, for at kunne afgøre, om der foreligger et ansættelsesforhold mellem den fysiske person og dette foretagende.
- 8.7 Da begrebet ansættelsesforhold, som omhandles i art. 15, skal fastsættes i henhold til den nationale lovgivning i den stat, der anvender overenskomsten (under hensyn til den begrænsning, der er omtalt i pkt. 8.11, og medmindre andet er bestemt i en overenskomst), følger det heraf, at en stat, der anser sådanne tjenesteydelser for at være tjenesteydelser i ansættelsesforhold, vil anvende art. 15 i overensstemmelse hermed. Den vil derfor logisk konkludere, at det foretagende, som tjenesteydelserne leveres til, har ansat den fysiske person med den følge, at foretagendet anses for arbejdsgiver ved anvendelse af stk. 2, litra b) og c). Denne konklusion er i

overensstemmelse med formålet med art. 15, stk. 2, da tjenesteydelserne i ansættelsesforholdet kan siges at være leveret til en person, der er hjemmehørende i den stat, hvor tjenesteydelserne udføres.

8.8 Som anført i pkt. 8.2 er det sådan, at selv hvor den nationale lovgivning i den stat, der anvender overenskomsten, ikke giver mulighed for at sætte spørgsmålstegn ved en formel kontraktmæssig aftale og derfor ikke tillader staten at anse tjenesteydelser leveret til et lokalt foretagende af en fysisk person, der formelt er ansat hos en person, der ikke er hjemmehørende i staten, for at være udført i et ansættelsesforhold hos det lokale foretagende, kan denne stat nægte anvendelsen af undtagelsen i stk. 2 i tilfælde af misbrug, således som det fremgår af art. 29, stk. 9 (jf. også pkt. 54-80 i kommentaren til art. 1).

8.9 (Ophævet)

8.10 Den fremgangsmåde, der er beskrevet i de forrige punkter, tillader derfor, at den stat, i hvilken virksomheden er udøvet, nægter at anvende stk. 2 i tilfælde af misbrug og i tilfælde, hvor, i henhold til denne stats definition af ansættelsesforhold i den nationale lovgivning, tjenesteydelser, der udføres til et lokalt foretagende af en fysisk person, der formelt er ansat i et udenlandsk foretagende, udføres i et ansættelsesforhold med det lokale foretagende. Denne fremgangsmåde sikrer, at lempelse af dobbeltbeskatning vil blive indrømmet af den stat, hvori personen er hjemmehørende, selv om denne stat ikke i henhold til sin nationale lovgivning finder, at der er et ansættelsesforhold mellem personen og det foretagende, til hvilket tjenesteydelserne leveres. Dette betyder, at så længe den stat, hvori personen er hjemmehørende, anerkender, at ansættelsesbegrebet i den nationale lovgivning i kildestaten eller eksistensen af ordninger, der indebærer misbrug af overenskomsten, tillader, at denne stat beskatter en persons arbejdsindkomst i overensstemmelse med overenskomsten, skal den førstnævnte stat indrømme lempelse for dobbeltbeskatning i henhold til de forpligtelser, der er fastlagt i art. 23 A og 23 B (se pkt. 32.1-32.7 i kommentaren til disse artikler). Den gensidige aftaleprocedure, der er omhandlet i art. 25, stk. 1, er anvendelig i tilfælde, hvor den stat, i hvilken personen er hjemmehørende, ikke er enig i, at den anden stat har anvendt den ovenfor beskrevne fremgangsmåde korrekt, og derfor ikke anser den anden stat for at have beskattet den relevante indkomst i overensstemmelse med overenskomsten.

8.11 Afgørelsen af, om der i henhold til den nationale lovgivning kan bortses fra et formelt kontraktmæssigt forhold, skal imidlertid træffes på grundlag af objektive kriterier. En stat kan f.eks. ikke hævde, at tjenesteydelser i henhold til dens nationale lovgivning anses for udført i et tjenesteforhold, hvis det ud fra de relevante faktiske omstændigheder klart fremgår, at disse tjenesteydelser udføres i henhold til en kontrakt mellem to separate foretagender om levering af tjenesteydelser. Den undtagelse, der er bestemt i art. 15, stk. 2, ville være meningsløs, hvis det var tilladt stater at anse tjenesteydelser for at være tjenesteydelser i et ansættelsesforhold i tilfælde, hvor der ikke er tale om et ansættelsesforhold, eller at nægte at anerkende, at et udenlandsk foretagende er arbejdsgiver, når det er klart, at det udenlandske foretagende leverer tjenesteydelser gennem egne ansatte til et foretagende, der drives af en person, der er hjemmehørende i den anden stat. Omvendt, når tjenesteydelser, der er udført af en fysisk person, med rette kan anses for udført i et ansættelsesforhold og ikke i henhold til en kontrakt mellem to foretagender om udførelse af tjenesteydelser, skal denne stat også logisk aner-

kende, at personen ikke udfører samme virksomhed som det foretagende, der er personens formelle arbejdsgiver; dette er f.eks. relevant ved afgørelsen af, om foretagendet har et fast driftssted på det sted, hvor den fysiske person udfører sin virksomhed.

8.12 Det er imidlertid ikke altid klart, om tjenesteydelser, der udføres af en fysisk person, af en stat med rette kan anses for udført i et ansættelsesforhold i stedet for i henhold til en kontrakt, indgået mellem to foretagender. Hvis staterne ikke er enige om, hvilken situation der foreligger, skal konflikten løses på grundlag af de nedenfor nævnte principper og eksempler (og ved anvendelsen af den gensidige aftaleprocedure, hvis dette findes hensigtsmæssigt).

8.13 Arten af de tjenesteydelser, der udføres af den fysiske person, er en vigtig faktor, da det er logisk at antage, at en ansat udfører tjenesteydelser, som er en integreret del af den forretningsmæssige virksomhed, der udøves af hans arbejdsgiver. Det er derfor vigtigt at fastslå, om de tjenesteydelser, der udføres af den fysiske person, udgør en integreret del af virksomheden i det foretagende, til hvilket disse tjenesteydelser leveres. Med henblik herpå vil det være væsentligt at fastslå, hvilket foretagende der bærer ansvaret eller risikoen for arbejdsresultatet. Det er imidlertid klart, at denne analyse kun er relevant, hvis de tjenesteydelser, der er udført af en fysisk person, er leveret direkte til et foretagende. Hvis f.eks. personen leverer tjenesteydelser til en kontraktproducent eller til et foretagende, til hvilket virksomheden er outsourcet, er personens tjenesteydelser ikke leveret til foretagender, der vil skaffe sig de omhandlede produkter eller tjenesteydelser.

8.14 Når en sammenligning af arten af de tjenesteydelser, der udføres af den fysiske person, med den virksomhed, der udøves af personens formelle arbejdsgiver og af det foretagende, til hvilket tjenesteydelserne er leveret, peger på et ansættelsesforhold, der er forskelligt fra det formelle kontraktforhold, kan følgende yderligere faktorer være relevante for at afgøre, om dette er tilfældet:

- hvem har retten til at instruere den fysiske person om, på hvilken måde arbejdet skal udføres
- hvem kontrollerer og har ansvaret for det sted, hvor arbejdet udføres
- den formelle arbejdsgiver har direkte afkrævet vederlaget til personen hos det foretagende, som tjenesteydelserne leveres til (jf. pkt. 8.15 nedenfor)
- hvem stiller nødvendige arbejdsredskaber og materiel til rådighed for personen
- hvem bestemmer antallet af personer, der skal udføre arbejdet, og deres kvalifikationer
- hvem har retten til at udvælge den person, som skal udføre arbejdet, og retten til at opsiges den kontrakt, der er indgået med personen vedrørende arbejdet
- hvem har retten til at pålægge personen sanktioner, der er relateret til personens arbejde
- hvem bestemmer personens arbejdstider og ferier.

8.15 Når en person, der formelt er ansat i et foretagende, leverer tjenesteydelser til et andet foretagende, er de økonomiske ordninger mellem de to foretagender klart relevante, om end ikke nødvendigvis afgørende, ved afgørelse af, om vederlaget til personen direkte af den formelle arbejdsgiver afkræves det foretagende, som tjenesteydelserne leveres til. Hvis f.eks. den betaling, der afkræves af det foretagende, der formelt beskæftiger personen, udgør det vederlag, og andre personaleomkostninger, der betales til personen for de tjenesteydelser, som personen leverer til det andet foretagende, uden

nogen avancemargin eller med tillæg af en avancemargin, der er beregnet som en procentdel af vederlaget og de øvrige personaleomkostninger, tyder dette på, at vederlaget til personen direkte af den formelle arbejdsgiver er afkrævet det foretagende, som tjenesteydelserne er leveret til. Dette skal imidlertid ikke anses for at være tilfældet, hvis den betaling, der er afkrævet for tjenesteydelserne, ikke har relation til vederlaget til personen, eller hvis dette vederlag kun er en af mange faktorer, der tages i betragtning ved fastsættelsen af det beløb, der afkræves i forbindelse med en egentlig kontrakt om levering af tjenesteydelser (f.eks. når et konsulentfirma debiterer en kunde på grundlag af et beløb pr. time for den tid, der er brugt af en af dets ansatte for at opfylde en bestemt kontrakt, og dette beløb tager foretagendets forskellige omkostninger i betragtning), forudsat at dette er i overensstemmelse med armlængdeprincippet, hvis de to foretagender er forbundne. Det er imidlertid vigtigt at være opmærksom på, at spørgsmålet om, hvorvidt vederlaget til personen direkte af den formelle arbejdsgiver er afkrævet det foretagende, som tjenesteydelserne leveres til, kun er en af de sekundære faktorer, der er relevante ved afgørelsen af, om tjenesteydelser, leveret af denne person, med rette af en stat kan anses for udført i et ansættelsesforhold og ikke i henhold til en kontrakt om levering af tjenesteydelser, indgået mellem to foretagender.

- 8.16. Eksempel 1: Aco, et selskab hjemmehørende i stat A, indgår en kontrakt med Bco, et selskab hjemmehørende i stat B, om levering af ydelser i form af instruktion. Aco har specialiseret sig i at instruere i brugen af forskellig computersoftware, og Bco ønsker at oplære sit personale i brugen af nyligt erhvervet software. X, som er ansat i Aco og hjemmehørende i stat A, er sendt til Bco i stat B for at levere instruktionskurser som en del af kontrakten.
- 8.17 I denne situation kan stat B ikke gøre gældende, at X er i et ansættelsesforhold med Bco, eller at Aco ikke er arbejdsgiver for X i henseende til overenskomsten mellem stat A og B. X er formelt ansat i Aco, hvis egne tjenesteydelser, set i lyset af de faktorer, der er angivet i pkt. 8.13 og 8.14, udgør en integreret del af virksomheden i Aco. De tjenesteydelser, som Aco leverer til Bco, er leveret på vegne af Aco i henhold til den kontrakt, der er indgået mellem de to foretagender. Hvis X herefter ikke er til stede i stat B i mere end 183 dage i en relevant 12-månedersperiode, og Aco ikke i stat B har et fast driftssted, som udreder vederlaget, finder undtagelsen i art. 15, stk. 2, anvendelse på vederlaget til X.
- 8.18. Eksempel 2: Cco, et selskab hjemmehørende i stat C, er moderselskab i en koncern, der indbefatter Dco, et selskab hjemmehørende i stat D. Cco har udviklet en ny verdensomspændende markedsstrategi for koncernens produkter. For at sikre, at strategien er forstået og følges af Dco, som sælger koncernens produkter, sender Cco X, der er en af de ansatte, der har arbejdet med udviklingen af strategien, til Dco's hovedkvarter for at rådgive Dco med hensyn til markedsføring og for at sikre, at Dco's kommunikationsafdeling forstår og følger den verdensomspændende strategi.
- 8.19 I dette tilfælde indbefatter virksomheden i Cco ledelsen af koncernens verdensomspændende markedsaktivitet, og de tjenesteydelser, der udføres af X, er en integreret del af denne virksomhed. Mens det kan gøres gældende, at Dco let kunne have ansat nogen til at udføre opgaven med at rådgive selskabet med hensyn til dets markedsføring, vil en sådan funktion hyppigt blive varetaget af en konsulent, især hvor der kræves en specialviden i et kortere tidsrum. Endvidere gælder, at funktionen med at overvåge overholdelsen af koncernens verdensomspændende markedsstrategi snarere henhører under virksomheden i Cco end under virksomheden i Dco. Undtagelsen i art. 15, stk. 2, skal derfor finde anvendelse, forudsat at bestemmelsens øvrige betingelser er opfyldt.
- 8.20. Eksempel 3: En multinational koncern ejer og driver hoteller i en række lande gennem et antal datterselskaber. Eco, et af disse datterselskaber, er hjemmehørende i stat E, hvor det ejer og driver et hotel. X er en ansat i Eco og arbejder på hotellet. Fco, et andet datterselskab i koncernen, ejer og driver et hotel i stat F, hvor der er mangel på personale med tilstrækkelige sprogkunderskaber. Af denne grund sendes X til Fco's hotel for at arbejde i receptionen i 5 måneder. Fco betaler rejseudgifterne for X, der forbliver ansat i og aflønnet af Eco. Endvidere betaler Fco en kommission, der er beregnet på grundlag af vederlaget til X samt sociale bidrag og andre personalegoder.
- 8.21 I dette tilfælde kan arbejdet i receptionen i stat F, i lyset af de faktorer, der er angivet i pkt. 8.13 og 8.14, anskues som udgørende en integreret del af Fco's virksomhed med hotel-drift snarere end som en del af virksomheden i Eco. Under henvisning til den fremgangsmåde, der er beskrevet ovenfor, kan stat F, hvis tjenesteydelserne udført af X i henhold til den nationale lovgivning i stat F anses for at være udført til Fco i et ansættelsesforhold, logisk være af den opfattelse, at Fco er arbejdsgiver for X. Undtagelsen i art. 15, stk. 2, finder herefter ikke anvendelse.
- 8.22. Eksempel 4: Gco er et selskab hjemmehørende i stat G. Dets virksomhed består i at opfylde virksomheders midlertidige behov for højt specialiseret arbejdskraft. Hco er et selskab hjemmehørende i stat H, som yder ingeniørbistand til byggevirksomheder. For at kunne opfylde en af sine kontrakter i stat H har Hco behov for en ingeniør i en periode på 5 måneder. Hco kontakter Gco. Gco ansætter X, en ingeniør hjemmehørende i stat X, henhold til en 5-månederskontrakt. I henhold til en særskilt kontrakt mellem Gco og Hco lover Gco at stille X til rådighed for Hco i denne periode. I henhold til disse kontrakter betaler Gco vederlaget til X, sociale bidrag, rejseudgifter og andre personalegoder samt øvrige udgifter.
- 8.23 I dette tilfælde udfører X arbejde som ingeniør, mens Gco udøver virksomhed med at opfylde foretagenders behov for arbejdskraft i kortvarige perioder. Ud fra deres art er de serviceydelser, der udføres af X, ikke en integreret del af hans formelle arbejdsgivers virksomhed. Disse tjenesteydelser er imidlertid en integreret del af virksomheden i Hco, der er et ingeniørfirma. I lyset af de faktorer, der er angivet i pkt. 8.13 og 8.14, kan stat H derfor med rette finde, at undtagelsen i art. 15, stk. 2, i henhold til den fremgangsmåde, der er beskrevet ovenfor, ikke finder anvendelse med hensyn til det vederlag for ingeniørens tjenesteydelser, der udføres i denne stat.
- 8.24. Eksempel 5: Ico, et selskab hjemmehørende i stat I, er specialist i at yde ingeniørbistand. Ico beskæftiger et antal ingeniører på fuld tid. Jco, et mindre ingeniørfirma hjemmehørende i stat J, har midlertidigt behov for en ingeniør for at opfylde en kontrakt om et anlægsarbejde i stat J. Ico aftaler med Jco, at en af Ico's ingeniører, der er hjemmehørende i stat I, og som for tiden ikke er beskæftiget med noget igangværende arbejde hos Ico, vil arbejde i 4 måneder for Jco under direkte tilsyn og kontrol af en af Jco's overordnede ingeniører. Jco vil betale Ico et beløb, der svarer til vederlaget til ingeniøren, sociale bidrag, rejseudgifter og andre udgifter i den relevante

periode, og yderligere en kommission på 5 %. Jco lover også at holde Ico skadesløs for eventuelle erstatningskrav, der har forbindelse med ingeniørens arbejde i den omhandlede periode.

- 8.25 I dette tilfælde er det klart, selv om virksomheden i Ico er at yde ingeniørbistand, at det arbejde, der udføres af ingeniøren i stat J, udføres på vegne af Jco og ikke på vegne af Ico. Det direkte tilsyn med og den kontrol af ingeniørens arbejde, der udøves af Jco, samt det faktum, at Jco har ansvaret for arbejdet og bærer omkostningerne med hensyn til vederlaget til ingeniøren i den relevante periode, er faktorer, der understøtter den konklusion, at ingeniøren er i et ansættelsesforhold til Jco. I henhold til den fremgangsmåde, der er beskrevet ovenfor, kan stat J derfor med rette finde, at undtagelsen i art. 15, stk. 2, ikke finder anvendelse med hensyn til vederlaget for ingeniørens tjenesteydelser, der udføres i denne stat.
- 8.26. Eksempel 6: Kco, et selskab hjemmehørende i stat K, og Lco, et selskab hjemmehørende i stat L, er en del af samme multinationale koncern. En stor del af koncernens virksomhed er struktureret "along function lines", hvilket indebærer, at ansatte i forskellige af koncernens selskaber arbejder sammen under tilsyn af ledere, som er lokaliseret i forskellige stater og ansat i andre af koncernens selskaber. X er hjemmehørende i stat K og ansat i Kco; hun er leder og beskæftiger sig med tilsyn med HR-funktioner ("human resources functions") inden for koncernen. Da X er ansat i Kco, fungerer Kco som et omkostningscenter for koncernens HR-omkostninger; med mellemrum bliver disse omkostninger debiteret hvert af selskaberne i koncernen på grundlag af en formel, der tager forskellige faktorer i betragtning, såsom antallet af ansatte i hvert selskab. X skal ofte rejse til andre stater, hvor andre selskaber i koncernen har deres kontorer. Sidste år tilbragte X tre måneder i stat L for at beskæftige sig med HR-spørgsmål i Lco.
- 8.27 I dette tilfælde er det arbejde, der udføres af X, en del af den virksomhed, som Kco udfører for de andre selskaber i koncernen. Denne virksomhed er i lighed med anden virksomhed såsom intern kommunikation, strategistyring, økonomistyring, skatteforvaltning, likviditetsstyring, informationsstyring og juridisk bistand ofte centraliseret inden for en koncern. Det arbejde, som X udfører, er således en integreret del af Kco's virksomhed. Undtagelsen i art. 15, stk. 2, bør derfor finde anvendelse på det vederlag, der oppebæres af X for hendes arbejde i stat L, forudsat at de øvrige betingelser for undtagelsen er opfyldt.
- 8.28 I tilfælde, hvor en stat, i overensstemmelse med de ovennævnte principper og eksempler, anser de tjenesteydelser, der af en fysisk person er udført på dens territorium, for udført i et ansættelsesforhold og ikke i henhold til en kontrakt om tjenesteydelser, indgået mellem to foretagender, er der en risiko for, at der stilles krav til foretagenderne om at indeholde kildeskat i vederlaget til personen i to jurisdiktioner, selv om dobbeltbeskatning i sidste instans vil blive undgået (jf. pkt. 8.10 ovenfor). Denne vanskelighed kan delvist afhjælpes, ved at skatteadministrationerne sikrer, at deres nationale regler og praksis vedrørende ansættelse er klare og let tilgængelige for arbejdsgivere. Problemet kan også delvist løses, hvis den stat, hvor personen er hjemmehørende, tillader foretagender hurtigt at regulere det skattebeløb, der skal indeholdes, for at tage højde for en lempelse af dobbeltbeskatning, der sandsynligvis vil blive indrømmet den ansatte.

Stk. 3

9. Stk. 3 finder anvendelse på vederlag til besætningsmedlemmer på skibe og luftfartøjer, der benyttes i international trafik, og i henhold til stykket beskattes sådanne vederlag kun i den stat, i hvilken den ansatte er hjemmehørende. Princippet om udelukkende beskatning i den stat, hvor den ansatte er hjemmehørende, blev indarbejdet i stykket ved en ændring i 2017. Formålet med ændringen var at skabe en klarere og administrativt enklere bestemmelse om beskatningen af vederlag til disse besætningsmedlemmer.
- 9.1 Samtidig blev definitionen af international trafik ændret for at sikre, at den også finder anvendelse på transport med et skib eller luftfartøj, der benyttes af et foretagende, der er hjemmehørende i en tredjestat. Som forklaret i pkt. 6.1 i kommentaren til art. 3 giver denne sidste ændring mulighed for at anvende art. 15, stk. 3, på en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, og som modtager vederlag for ansættelse på et skib eller luftfartøj, der anvendes af et foretagende, der er hjemmehørende i en tredjestat.
- 9.2 Hvis arbejdet imidlertid udføres af en ansat, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, på et skib eller et luftfartøj, der udelukkende benyttes til transport inden for den anden stat, vil det klart være urimeligt at give en udelukkende beskatningsret til den stat, hvori den ansatte er hjemmehørende. Udtrykket "medmindre det sker om bord på et skib eller luftfartøj, der benyttes til transport i den anden kontraherende stat" sikrer, at stykket ikke finder anvendelse på en sådan ansat, hvilket betyder, at beskatningen af denne ansattes vederlag er omfattet af bestemmelserne i artiklens stk. 1 og 2.
- 9.3 Som anført i pkt. 9 ovenfor, finder stk. 3 anvendelse på besætningsmedlemmer på skibe og luftfartøjer. Dette fremgår klart af henvisningen til arbejde "udført som besætningsmedlem på et skib eller luftfartøj". Disse ord dækker bredt nok til at omfatte alle former for arbejde udført som led i skibets eller luftfartøjets sædvanlige drift, herunder f.eks. arbejde udført af ansatte i restauranter på et krydstogtskib eller arbejde udført af en stewardesse, som flyver sin sidste tur, før hun fratræder. De omfatter derimod ikke arbejde, som kan udføres på et skib eller fly, men som ikke har relation til driften af dette (f.eks. en ansat i et forsikringselskab, der sælger hus- og bilforsikringer til passagererne på et krydstogtskib).
- 9.4 Som der er gjort rede for i pkt. 15 i kommentaren til art. 8, kan stater, der ønsker at behandle transport på floder, kanaler og søer på samme måde som skibs- eller luftfartøjsvirksomhed i international trafik, udvide anvendelsesområdet for art. 8 til også at omfatte fortjeneste erhvervet ved drift af både i forbindelse med transport ad indre vandveje. Disse stater kan ønske at anvende art. 15, stk. 3, på vederlag til de ansatte, der arbejder på disse både. Hvis der er tale om vederlag erhvervet af en ansat, der arbejder på en båd, der anvendes ved transport ad indre vandveje, bør stk. 3 dog kun finde anvendelse i det omfang, båden anvendes af et foretagende, der er hjemmehørende i den stat, hvor den ansatte er hjemmehørende. Det ville være urimeligt at kræve af en kontraherende stat, at den skulle undtage vederlag erhvervet af en ansat, som er hjemmehørende i den anden stat, men som er ansat af et foretagende i den førstnævnte stat (eller i en tredjestat, med hvilken den førstnævnte stat ikke har indgået aftale om at undtage fortjeneste erhvervet ved drift af både i forbindelse med transport ad indre vandveje), hvis dette vederlag vedrører arbejde, der er udført udelukkende i den førstnævnte stat. Kontraherende stater, der ønsker at tage højde for denne problemstilling, kan i deres bilaterale overenskomst indsætte

en særskilt bestemmelse, der omhandler besætningsmedlemmer på både, der benyttes til transport ad indre vandveje, og som kan affattes som følger:

“Uanset de foranstående bestemmelser i denne artikel og i art. 1 kan vederlag erhvervet af en fysisk person, uanset om vedkommende er hjemmehørende i en kontraherende stat eller ej, for arbejde udført som besætningsmedlem på en båd, der benyttes til transport ad indre vandveje i en kontraherende stat, og som benyttes af et foretagende i den anden stat, kun beskattes i denne anden stat”. Sådanne vederlag kan imidlertid også beskattes i den førstnævnte stat, hvis de erhverves af en person, der er hjemmehørende i denne stat.

- 9.5 Som nævnt i pkt. 2 i kommentaren til art. 8 kan nogle stater foretrække at give den udelukkende ret til at beskatte fortjeneste ved skibs- og luftfart til den stat, i hvilken foretagendets virkelige ledelse har sit sæde, frem for den stat, hvor foretagendet er hjemmehørende. Hvis de kontraherende stater vælger denne løsning, bør der foretages en tilsvarende ændring af de alternative bestemmelser i pkt. 9.4 ovenfor og pkt. 9.6 nedenfor, hvis disse bestemmelser anvendes.

- 9.6 Nogle stater foretrækker at give mulighed for at lade vederlag erhvervet af en ansat, der arbejder på et skib eller et luftfartøj i international trafik, beskattes af både den stat, hvori foretagendet, der anvender skibet eller luftfartøjet, er hjemmehørende, og den stat, hvori den ansatte er hjemmehørende. Stater, der ønsker dette, kan affatte stk. 3 som følger:

3. “Uanset de foranstående bestemmelser i denne artikel og i art. 1 kan vederlag erhvervet af en fysisk person, uanset om vedkommende er hjemmehørende i en kontraherende stat eller ej, for arbejde, der udføres som besætningsmedlem på et skib eller luftfartøj i international trafik, som anvendes af et foretagende i en kontraherende stat, kun beskattes i denne kontraherende stat. Hvis et sådant vederlag imidlertid erhverves af en person, der er hjemmehørende i den anden kontraherende stat, kan det også beskattes i denne anden stat”.

- 9.7 Nogle stater, der ønsker at anvende denne løsning, kan også ønske at begrænse anvendelsen af stk. 3 til ansatte, som er hjemmehørende i en af de kontraherende stater, hvilket kan gøres ved at anvende følgende ordlyd:

3. “Uanset de foranstående bestemmelser i denne artikel kan vederlag erhvervet af en person hjemmehørende i en kontraherende stat for arbejde udført som besætningsmedlem på et skib eller et luftfartøj i international trafik alene beskattes i denne stat. Hvis skibet eller luftfartøjet imidlertid anvendes af et foretagende, der er hjemmehørende i den anden kontraherende stat, kan et sådant vederlag også beskattes i den anden stat”.

- 9.8 I henhold til den alternative bestemmelse i pkt. 9.6 ovenfor har den kontraherende stat, hvor foretagendet er hjemmehørende, den primære ret til at beskatte den ansattes vederlag. Hvis den ansatte er hjemmehørende i den anden kontraherende stat, kan vederlaget også beskattes i denne anden stat, idet denne stat dog er forpligtet til at indrømme lempelse for dobbeltbeskatning i henhold til bestemmelserne i art. 23 A eller 23 B.

- 9.9 Da den alternative bestemmelse tillader beskatning i den stat, hvor det foretagende, der anvender skibet eller luftfartøjet, er hjemmehørende, kan den bidrage til at håndtere den situationen, hvor ansatte, som i et betydeligt omfang arbejder om bord på skibe eller luftfartøjer i international trafik, og som

kan finde det fordelagtigt at være hjemmehørende i stater, som opkræver ingen eller kun en beskeden skat på arbejdsindkomst erhvervet ved sådant arbejde, der udføres uden for deres territorium. Udgangspunktet for bestemmelsen er imidlertid, at de kontraherende stater har mulighed for i henhold til deres nationale lovgivning at beskatte vederlag erhvervet af ansatte, der arbejder om bord på skibe eller luftfartøjer i international trafik, udelukkende fordi de foretagender, der anvender disse skibe eller luftfartøjer, er hjemmehørende i disse stater. Hvis dette ikke er tilfældet, er der ved anvendelsen af denne bestemmelse i kombination med eksemptionsmetoden til ophævelse af dobbeltbeskatning risiko for, at der slet ikke sker beskatning. Antag f.eks., at ovennævnte bestemmelse indgår i en overenskomst mellem stat R og stat S, at stat R anvender eksemptionsmetoden, og at en ansat, der er hjemmehørende i stat R, arbejder på flyruter mellem stat R og tredjestater, der drives af et flyselskab, der er hjemmehørende i stat S. Hvis den nationale lovgivning i stat S ikke giver stat S mulighed for at beskatte vederlag erhvervet af flyselskabets ansatte, som ikke er hjemmehørende i stat S, og som ikke arbejder i stat S, vil stat S i dette tilfælde ikke kunne udøve den ret til beskatning, som er blevet tillagt den, men stat R vil skulle undtage sådanne vederlag fra beskatning, fordi stat S i henhold til overenskomstens bestemmelser har retten til at beskatte disse vederlag.

- 9.10 Som det forklares i pkt. 3 i kommentaren til art. 8, kan det bestemmes, at henvisningen til sædet for foretagendets virkelige ledelse i den alternative bestemmelse i pkt. 2 i kommentaren finder anvendelse, hvis en skibsfartsvirksomheds virkelige ledelse har sit sæde om bord på et skib. Ifølge nogle landes nationale lovgivning beskattes vederlag, der erhverves af ikke-hjemmehørende besætningsmedlemmer for arbejde udført om bord på skibe, kun, hvis skibet har denne stats nationalitet. Af denne grund bestemmes det i overenskomster, der er indgået mellem disse lande, at beskatningsretten til sådant vederlag gives den stat, hvis nationalitet skibet har. På den anden side kan mange stater ikke gøre brug af en sådan beskatningsret, og bestemmelsen kan i sådanne tilfælde føre til ikke-beskatning svarende til den situation, der er beskrevet i foregående punkt. Stater, hvis nationale lovgivning indeholder dette princip, kan imidlertid bilateralt aftale at give beskatningsretten til vederlag for arbejde, udført om bord på skibe, til den stat, hvis nationalitet skibet har.

10. Det skal bemærkes, at der ikke er anført en særlig regel med hensyn til beskatningen af indkomsten hos grænsegængere eller hos ansatte, der arbejder på lastbiler eller tog, der opererer mellem stater, idet det forekommer mest hensigtsmæssigt, at de problemer, der er skabt af lokale forhold, løses direkte af de pågældende stater.

11. Der er ikke fastsat nogen særlig bestemmelse angående gæstelærere eller studerende, der har beskæftigelse med henblik på at opnå praktisk erfaring. Mange overenskomster indeholder regler af en eller anden slags om disse tilfælde, hvis hovedformål er at fremme kulturelle forbindelser ved at foreskrive en begrænset skattefritagelse. Skattefritagelsen er undertiden allerede fastsat i national skattelovgivning. Manglen på særlige regler skal ikke tolkes således, at dette udgør en hindring for at indsætte sådanne regler i bilaterale overenskomster, når dette forekommer ønskeligt.

Lønmodtageres aktieoptioner (medarbejderaktier)

12. Landenes forskellige regler for beskatningen af lønmodtageres aktieoptioner medfører særlige problemer, der behandles

nedenfor. Mens mange af disse problemer opstår med hensyn til andre former for aflønning, er især de, der vedrører værdien af aktier, særlig store for så vidt angår aktieoptioner. Dette skyldes i vidt omfang det forhold, at aktieoptioner ofte beskattes på et tidspunkt (f.eks. når optionen udnyttes eller aktierne sælges), der er forskelligt fra det tidspunkt, hvor de arbejdsydelse, for hvilke disse optioner udgør et vederlag, er udført.

- 12.1 Som anført under pkt. 2.2 tillader artiklen, at kildestaten beskatter den del af aktieoptionens værdi, der udgør vederlag erhvervet i forbindelse med ansættelsesforholdet i denne stat, selv om skatten pålignes på et senere tidspunkt, hvor den ansatte ikke længere er ansat i denne stat.
- 12.2 Selv om artiklen finder anvendelse på det ansættelsesgode, der hidrører fra en aktieoption, der er tildelt en ansat, uanset hvornår godet beskattes, er det nødvendigt at adskille dette ansættelsesgode fra den kapitalgevinst, der kan opnås ved afståelse af aktier erhvervet ved udnyttelsen af optionen. Denne artikel, og ikke art. 13, finder anvendelse på ethvert gode, der hidrører fra selve optionen, indtil den er blevet udnyttet, solgt eller på anden måde er afstået (f.eks. ved at blive annulleret eller ved at være erhvervet af arbejdsgiveren eller udstederen). Når optionen imidlertid er blevet udnyttet eller er afstået, er ansættelsesgodet blevet realiseret, og enhver efterfølgende gevinst på de erhvervede aktier (dvs. den værdistigning på aktierne, der opnås efter udnyttelsen) erhverves af den ansatte i dennes egenskab af aktieinvestor og vil være omfattet af art. 13. Forholdet er reelt det, at det er på udnyttelsestidspunktet, at optionen, som den ansatte erhvervede i forbindelse med sin ansættelse, ophører med at eksistere, og den ansatte er herefter aktionær (og har sædvanligvis investeret penge for at blive aktionær). Hvis den option, der er blevet udnyttet, imidlertid giver den ansatte ret til at erhverve aktier, der ikke vil blive endeligt overdraget før ved udgangen af en vis nærmere fastsat ansættelsesperiode, vil det være rigtigst at anvende denne artikel på den eventuelle værdistigning, der måtte opnås indtil udgangen af den fastsatte ansættelsesperiode, der følger efter udnyttelsen af optionen.
- 12.3 Det forhold, at artiklen ikke finder anvendelse på et gode, der er opnået efter udnyttelsen eller afhændelsen af optionen, indebærer ikke på nogen måde, at beskatning af arbejdsindkomsten skal finde sted på tidspunktet for udnyttelsen eller afhændelsen. Som allerede anført begrænser artiklen ikke den måde, på hvilken kildestaten kan beskatte den relevante indkomst. Kildestaten kan således beskatte den relevante indkomst på det tidspunkt, hvor optionen bliver tildelt, på det tidspunkt, hvor optionen udnyttes (eller afhændes), på det tidspunkt, hvor aktien sælges, eller på ethvert andet tidspunkt. Kildestaten kan imidlertid kun beskatte de goder, der kan henføres til selve optionen, og ikke det, der kan henføres til den efterfølgende besiddelse af aktier, der er erhvervet ved udnyttelse af optionen (undtagen i de tilfælde, der er omtalt i det sidste punktum i det foregående punkt).
- 12.4 Da stk. 1 skal fortolkes således, at det finder anvendelse på ethvert gode, der hidrører fra optionen, indtil den er blevet udnyttet, solgt eller på anden måde afhændet, er det uden betydning, hvorledes dette gode, eller en del deraf, karakteriseres efter nationale skatteregler. Følgelig vil det, så længe artiklen fortolkes således, at den tillader, at kildestaten beskatter de goder, der vedrører perioden op til det tidspunkt, hvor optionen er blevet udnyttet, solgt eller på anden måde afhændet, være overladt til denne stat at bestemme, hvorledes

sådanne goder skal beskattes, f.eks. enten som arbejdsindkomst eller som kapitalindkomst. Hvis kildestaten f.eks. beslutter at pålægge en kapitalgevinstskat på optionen, når den ansatte ophører med at være hjemmehørende i denne stat, vil denne beskatning være tilladt i henhold til artiklen. Det samme vil være tilfældet for den stat, hvor personen er hjemmehørende. Selv om denne stat vil have den udelukkende beskatningsret til den værdistigning på aktien, der er opnået efter udnyttelsen af optionen, da denne bliver anset for at falde ind under art. 13, kan den eksempelvis godt, i henhold til sin nationale lovgivning, vælge at beskatte værditilvæksten som arbejdsindkomst i stedet for som kapitalindkomst.

- 12.5 De goder, der hidrører fra en aktieoption, der er tildelt en ansat, vil som hovedregel hverken falde ind under art. 21, der ikke finder anvendelse på indkomst, der er omfattet af andre artikler, eller art. 18, der kun finder anvendelse på pensioner og andre lignende vederlag, selv hvis optionen er udnyttet efter ansættelsens ophør.
- 12.6 Stk. 1 giver kildestaten ret til at beskatte gage, løn og andet lignende vederlag for arbejde udført i denne stat. Afgørelsen af, om og i hvilket omfang en aktieoption hidrører fra arbejde udført i en bestemt stat, skal i hvert enkelt tilfælde træffes på grundlag af alle relevante forhold og omstændigheder, herunder de kontraktmæssige betingelser, der er knyttet til optionen (f.eks. betingelserne for, at den tildelte option kan udnyttes eller afhændes). Nedennævnte generelle principper skal følges.
- 12.7 Det første princip er, at en aktieoption som hovedregel ikke skal anses for at have forbindelse med tjenesteydelser udført efter den ansættelsesperiode, der er krævet som betingelse for, at den ansatte har erhvervet ret til at udnytte optionen. Når en aktieoption således er tildelt en ansat på den betingelse, at den ansatte udfører arbejde for den samme arbejdsgiver (eller for et forbundet foretagende) i en periode på tre år, skal det ansættelsesgode, der hidrører fra optionen, generelt ikke anses for knyttet til tjenesteydelser udført efter treårsperioden.
- 12.8 Ved anvendelsen af det ovennævnte princip er det imidlertid vigtigt at sondre mellem en ansættelsesperiode, der er krævet for at opnå retten til at udnytte en aktieoption, og en tidsperiode, som blot er en udskydelse af det tidspunkt, hvor optionen kan udnyttes. Hvis f.eks. en option, der er tildelt en ansat på den betingelse, at den pågældende vedbliver med at være ansat hos den samme arbejdsgiver (eller et forbundet foretagende) i en periode på tre år, kan optionen anses for at hidrøre fra de tjenesteydelser, der er udført i denne treårsperiode. Forholdet er anderledes med hensyn til en option, der – uden at der er stillet betingelse om efterfølgende ansættelse – tildeles en ansat på en given dato, men som, i henhold til betingelserne, først kan udnyttes, efter at der er forløbet tre år. I dette tilfælde kan optionen ikke anses for at hidrøre fra det arbejde, der er udført i disse tre år, da fordelene ved en sådan option ville komme modtageren til gode, selv om modtageren skulle forlade sit arbejde umiddelbart efter at have modtaget optionen og vente de foreskrevne tre år, før den blev udnyttet.
- 12.9 Det er også vigtigt at sondre mellem en situation, hvor der kræves en ansættelsesperiode som betingelse for erhvervelsen af retten til at udnytte en option, dvs. overdragelsen af optionen, og en situation, hvor en option, der allerede er overdraget, kan fortabes, hvis den ikke er udnyttet, før ansættelsen er ophørt (eller inden for en kort periode herefter). I den sidstnævnte situation bør optionen ikke anses for at være knyttet til tjenesteydelser udført efter overdragelsen, da den

ansatte allerede har erhvervet godet og reelt kan realisere det på et hvilket som helst tidspunkt. En betingelse, ifølge hvilken den overdragede option fortabes, hvis ansættelsen ophører, er ikke en betingelse for erhvervelsen af godet, men snarere en betingelse, i henhold til hvilken det allerede erhvervede gode efterfølgende kan fortabes. De følgende eksempler belyser denne sontring:

- Eksempel 1: Den 1. januar i år 1 tildeles en ansat en aktieoption. Erhvervelsen af optionen er betinget af, at den ansatte fortsat er ansat af den samme arbejdsgiver indtil 1. januar i år 3. Optionen kan, når denne betingelse er opfyldt, udnyttes fra 1. januar i år 3 indtil 1. januar i år 10 (en såkaldt amerikansk option²). Det er imidlertid yderligere bestemt, at enhver udnyttet option fortabes ved ansættelsens ophør. I dette eksempel er retten til at udnytte optionen blevet erhvervet den 1. januar i år 3 (dvs. på overdragelsesdagen), da der ikke er stillet krav om en yderligere ansættelsesperiode, for at den ansatte opnår ret til at udnytte optionen.
 - Eksempel 2: Den 1. januar i år 1 tildeles en ansat en aktieoption. Optionen kan udnyttes den 1. januar i år 5 (en såkaldt europæisk option). Optionen er tildelt på den betingelse, at den kun kan udnyttes den 1. januar i år 5, hvis ansættelsesforholdet ikke er ophørt før denne dato. I dette eksempel erhverves retten til at udnytte optionen først den 1. januar i år 5, der er den dato, hvor den kan udnyttes, da en ansættelse indtil denne dato er påkrævet for at erhverve retten til at udnytte optionen (dvs. efter vestingperioden).
- 12.10 Der er tilfælde, hvor dette første princip ikke kan finde anvendelse. Et sådant tilfælde kan være, hvis aktieoptionen er tildelt en ansat uden betingelser på det tidspunkt, hvor den ansatte enten påbegynder et ansættelsesforhold, er forflyttet til et nyt land eller er tildelt et nyt betydningsfuldt ansvarsområde og, i det konkrete tilfælde, optionen tydeligt har relation til de nye funktioner, der skal udføres af den ansatte inden for en nærmere fastsat fremtidig tidsperiode. I et sådant tilfælde kan det være rigtigst at anse denne option for at være knyttet til disse nye funktioner, selv om retten til at udnytte optionen er tildelt, før funktionerne er udført. Der er også tilfælde, hvor der rent teknisk er tildelt en option, men hvor optionen berettiger den ansatte til at erhverve aktier, der ikke vil blive overdraget før efter en fastsat ansættelsesperiode. I sådanne tilfælde kan det være rigtigst at anse godet hidrørende fra optionen for at være knyttet til de tjenesteydelser, der udføres i hele perioden mellem tildelingen af optionen og overdragelsen af aktierne.
- 12.11 Det andet princip er, at en aktieoption kun skal anses for at have tilknytning til tjenesteydelser, der er udført, før optionen blev tildelt, i det omfang tildelingen af optionen er en anerkendelse af modtagelsen af tjenesteydelser udført i en bestemt periode. Dette vil eksempelvis være tilfældet, hvor tildelingen af optionen påviseligt er sket på grund af den ansattes tidligere arbejde gennem en bestemt periode eller er sket på grund af arbejdsgiverens tidligere økonomiske resultater og er betinget af, at den ansatte har været ansat hos arbejdsgiveren eller et forbundet foretagende i en bestemt periode, som de økonomiske resultater vedrører. Der kan også i nogle tilfælde være objektive forhold, der viser, at der mellem deltagerne i en aktieoptionsordning i en tidligere ansættelsesperiode var en velbegrundet forventning om, at de ville modtage en del af deres aflønning for denne periode ved på et senere tidspunkt at få tildelt aktieoptioner. Et sådant forhold kan eksempelvis være arbejdsgiverens faste praksis med gennem en årrække at have tildelt tilsvarende aktieoptioner, forudsat at der ikke var forhold, der viste, at denne praksis kunne ændres. Afhængigt af andre faktorer kan sådanne forhold være særdeles relevante ved afgørelsen af, om og i hvilket omfang aktieoptionen er knyttet til sådant tidligere udført arbejde.
- 12.12 Når en ansættelsesperiode er en betingelse for at opnå retten til at udnytte en aktieoption, men hvor en sådan betingelse ikke kan opfyldes i visse tilfælde, f.eks. hvor ansættelsesforholdet er bragt til ophør af arbejdsgiveren, eller hvor den ansatte når pensionsalderen, kan det til aktieoptionen knyttede gode kun anses for at vedrøre den faktiske ansættelsesperiode, da disse omstændigheder indtrådte.
- 12.13 Endelig kan der være situationer, hvor nogle forhold peger på, at en aktieoption er vederlag for tidligere tjenesteydelser, men hvor andre forhold synes at vise, at aktieoptionen er vederlag for fremtidige tjenesteydelser. I tvivlstilfælde skal der henses til, at aktieoptioner almindeligvis tildeles som et incitament til fremtidig ansættelse eller som et middel til at holde på værdifulde ansatte. Aktieoptioner relaterer sig således primært til fremtidige ansættelsesforhold. Alle relevante omstændigheder skal imidlertid tages i betragtning før en afgørelse kan træffes, og der kan være tilfælde, hvor det kan påvises, at en aktieoption vedrører både tidligere og fremtidige ansættelse (f.eks. optioner, der er tildelt som følge af, at den ansatte har gjort sig fortjent til det i de forudgående år, men hvor optionen kun kan udnyttes, hvis den ansattes ansættelse fortsætter i yderligere tre år).
- 12.14 Når en aktieoption ud fra de foregående principper bliver anset for at være tildelt for arbejde udført i mere end én stat, er det nødvendigt at afgøre, hvilken del af det til aktieoptionen knyttede gode der relaterer sig til arbejde, udført i hver stat ved anvendelsen af artiklen og art. 23A og 23B. I dette tilfælde skal det ansættelsesgode, der kan henføres til aktieoptionen, anses for at hidrøre fra et bestemt land i forholdet mellem antallet af dage, hvor arbejdet er blevet udført i dette land, og det totale antal dage, hvor arbejdsydelse, som optionen hidrører fra, er blevet udført. Ved beregningen skal alene de af ansættelsesforholdet omfattede dage, der er relevante for aktieoptionsplanen, tages i betragtning, dvs. de dage, hvor der er udført arbejde for den samme arbejdsgiver eller for andre arbejdsgivere, når ansættelsen hos disse bliver taget i betragtning ved fastsættelsen af den ansættelsesperiode, der kræves for at opnå retten til at udnytte optionen.
- 12.15 Det er muligt for medlemslandene at fravige anvendelsen af de under pkt. 12.7-12.14 anførte principper ved bilateralt at aftale en særlig fremgangsmåde. F.eks. kan to lande, der overvejende beskatter ved udnyttelsen af en option, som et generelt princip aftale at henføre indkomsten fra en option, der primært relaterer sig til fremtidige tjenesteydelser, til de tjenesteydelser, der er udført af en ansat i de to stater mellem datoen for tildelingen og udnyttelsen. I tilfælde, hvor optioner, der ikke kan udnyttes, før den ansatte har udført tjenesteydelser for arbejdsgiveren i en nærmere bestemt periode, kan de to stater således aftale en fremgangsmåde, der henfører

² For så vidt angår en "amerikansk" aktieoption kan retten til at erhverve en aktie udnyttes inden for en bestemt tidsperiode (typisk et bestemt antal år), mens denne ret ved en europæisk option kun kan udnyttes på et bestemt tidspunkt (dvs. på en bestemt dato).

indkomsten fra optionen til hver stat, baseret på det antal dage, den ansatte for arbejdsgiveren har udført arbejde i hver af staterne i perioden mellem tildelingen og udnyttelsen. Et andet eksempel vil være, at to lande, der har samme regler for beskatning af aktieoptioner, aftaler bestemmelser, der giver den ene af de kontraherende stater den udelukkende beskatningsret til optionen, selv om en mindre del af de tjenesteydelser, der vedrører optionen, er blevet udført i den anden stat. Medlemslande skal naturligvis være forsigtige med at anvende sådanne fremgangsmåder, fordi de kan medføre dobbeltbeskatning eller dobbelt ikke-beskatning, hvis en del af arbejdet er udført i en tredjestat, der ikke anvender en lignende fremgangsmåde.

Bemærkninger til kommentaren

13. *Frankrig* er af den opfattelse, at pkt. 8.13 ikke skal fortolkes som værende tilstrækkelig i sig selv til at sætte spørgsmålstegn ved et formelt kontraktforhold. Hvis, i henseende til pkt. 8.13, de tjenesteydelser, der udføres af en fysisk person, udgør en integreret del af virksomheden i det foretagende, som tjenesteydelserne leveres til, skal situationen analyseres i overensstemmelse med bestemmelserne i pkt. 8.14.
- 13.1 For så vidt angår pkt. 6.2 har *Tyskland* det synspunkt, at et interessentskab som sådant skal anses for arbejdsgiver (som det er tilfældet i henhold til den nationale lovgivning i de fleste OECD-medlemsstater, selv om disse stater ikke beskatter selve interessentskabet). Hvor interessentskabet er hjemmehørende, skal så afgøres hypotetisk, som om interessentskabet var skattepligtigt som følge af et af de kriterier, der er anført i art. 4, stk. 1.

Forbehold til artiklen

14. *Slovenien* forbeholder sig ret til at tilføje en artikel, der, under visse betingelser, behandler situationen for lærere, professorer og forskere, og ret til at ændre art. 15, stk. 1, tilsvarende.
15. *Danmark, Norge* og *Sverige* forbeholder sig ret til at indsætte særlige bestemmelser angående vederlag for arbejde i ansættelsesforhold, der udføres om bord på et luftfartøj i international trafik, som drives af luftfartsselskabet Scandinavian Airlines System (SAS).

16. *Norge* forbeholder sig ret til i stk. 2 at indsætte en udtrykkelig henvisning til indkomst, der i en kontraherende stat er erhvervet af personale, der er udlejet fra den anden kontraherende stat, med henblik på at tydeliggøre den forståelse, at undtagelsen i stk. 2 ikke finder anvendelse i situationer, hvor der foreligger "international arbejdsudlejning", (jf. stk. 8 ovenfor).
17. *Irland, Norge* og *Storbritannien* forbeholder sig ret til i en særskilt artikel at indsætte bestemmelser om indkomst, der erhverves ved personligt arbejde i tjenesteforhold, der står i forbindelse med offshore-efterforskning og udnyttelse af kulbrinteforekomster samt virksomhed i tilknytning hertil.
18. *Letland* forbeholder sig ret til i en særskilt artikel at indsætte bestemmelser om indkomst, der er erhvervet i ansættelsesforhold, der vedrører virksomhed, som udøves offshore i en kontraherende stat i forbindelse med efterforskning eller udnyttelse af naturforekomster på havbunden eller i dens undergrund.
19. *Schweiz* forbeholder sig sin stilling med hensyn til stk. 2, litra a), og ønsker i sine overenskomster at indsætte udtrykket "inden for det pågældende skatteår" i stedet for udtrykket "i en 12-månedersperiode, der begynder eller slutter i det pågældende skatteår".
20. Under hensyn til sin særlige situation hvad angår shipping vil *Grækenland* beholde sin handlefrihed med hensyn til de bestemmelser i overenskomsten, som vedrører vederlag til besætningsmedlemmer på skibe i international trafik.
21. *Grækenland* forbeholder sig ret til at indsætte særlige bestemmelser vedrørende virksomhed offshore.
22. *Tyrkiet* forbeholder sig med hensyn til stk. 3 eneret til at beskaffe vederlag erhvervet for ansættelse om bord på et skib eller luftfartøj i international trafik, der anvendes af et foretagende hjemmehørende i Tyrkiet.